

1501606-18.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Elaine Cristina Pulcineli Vieira Gonçalves

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 15ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/03/2022

... já transitada em julgado conforme certidão de fls. 40 por tráfico ilícito de entorpecentes (0025388-32.2012.8.26.0050), que será aqui considerada como maus antecedentes, devendo a pena base ser aumentada em 1/6, nos termos do disposto no art. 59 do Código Penal, perfazendo, 2 anos, 4 meses e 11 dias-multa.

Não há que se falar em desconsideração das condenações acima apontadas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

15ª Vara Criminal

Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1501606-18.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501606-18.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CINTIA RAQUEL DE SOUZA MEDINA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Elaine Cristina Pulcineli Vieira Gonçalves

Vistos.

CINTIA RAQUEL DE SOUZA MEDINA e PEDRO DOS SANTOS, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no art.155, § 4º, incisos II e IV, pois, segundo apurado, no dia 20 de janeiro de 2022, por volta das 14h52min, na Rua Vicente Biondo, nº 102, Casa Verde, São Paulo/SP, agindo em concurso e com unidade de desígnios entre si, subtraíram para si, mediante escalada, coisas alheias móveis consistentes em 30 metros de cabo de energia elétrica, duas facas, uma serra, um martelo, uma chave de fenda, uma luminária e um cano de rede de esgoto, pertencentes à vítima C.M.J., avaliados em R\$ 400,00.

A denúncia foi recebida, os acusados foram citados e notificados, e apresentaram resposta à acusação.

Após a manutenção do recebimento da denúncia, em sede de audiência de instrução, debates e julgamento foram ouvidos a vítima, dois policiais e os réus foram interrogados.

Encerrada a instrução criminal, em seus memoriais o Ministério Público requereu a parcial procedência da ação penal, com a condenação do acusados pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas em sua forma tentada.

A Defesa dos acusados, por sua vez, buscou a absolvição dos acusados com fundamento no artigo 386, inciso, III, do Código de Processo Penal, alegando em suma, que os fatos ocorreram em um local abandonado. Subsidiariamente, em caso de eventual condenação, pugnou pela fixação da pena no mínimo legal, o afastamento da qualificadora da escalada, o reconhecimento da confissão a ambos os acusados, e da

atenuante da menoridade para a ré Cintia, o afastamento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "j", o reconhecimento da tentativa e a fixação do regime aberto para início de cumprimento de pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, no que toca a ré Cintia e para o corréu Pedro, ao menos regime diverso do fechado, além do direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Sem duvidas que a absolvição dos acusados é descabida, já que os fatos narrados na denúncia vieram devidamente comprovados durante a instrução criminal.

Os dois réus interrogados em juízo, confessaram a prática do crime, afirmando que entraram no local após pularem o muro e de lá retiraram os objetos descritos na denuncia, sendo surpreendidos pela polícia ainda dentro do local. Disseram, ainda, que os bens estavam todos no chão já devidamente separados para serem levados. A confissão dos acusados foi corroborada pelas declarações da vítima e dos dois policiais.

Com efeito, a vítima C.M.J, ao ser ouvido em juízo, alegou que é o proprietário do imóvel onde, antigamente existia uma escola. No dia dos fatos recebeu um telefonema no qual foi solicitado a comparecer na Delegacia já que alguns furtadores teriam ingressado no imóvel e de lá subtraído fios de energia elétrica, uma luminária e outros objetos que se encontravam no interior do imóvel. Não chegou a ir ao Distrito Policial pois estava se recuperando de uma cirurgia do coração.

Os policiais ouvidos nesta data, após prestarem o compromisso de dizer a verdade, afirmaram que foram acionados para atender uma ocorrência de invasão a um imóvel, onde antigamente funcionava uma escola e para lá se dirigiram. Logo que ali ingressaram se depararam com os réus, já tentando pular o muro da parte de trás do imóvel, com vários objetos em sua posse e em razão disso ambos foram presos e levados à Delegacia de Polícia onde foi lavrado o boletim de ocorrência.

Mostra-se, pois, suficiente à condenação dos acusados aos elementos coligidos durante a instrução, já que a prova suficiente à condenação por furto não é daquelas contundentes, vistosas, bastando apreciação adequada de elementos formadores de convicção autorizadores da certeza de participação do acusado no evento.

É de asseverar, ainda, que o simples fato de as testemunhas ouvidas serem policiais nada significa para que sejam desconsiderados seus depoimentos ou que estes sejam recebidos com reservas, mesmo que não tenham sido arroladas outras testemunhas.

Neste compasso, imprescindível salientar que é entendimento pacífico em nossa jurisprudência que os depoimentos de policiais, apenas pela sua condição, não podem ser desconsiderados ou desacreditados, em primeiro lugar porque, constitucionalmente, são os policiais aptos, como qualquer cidadão, a prestar testemunho sob o compromisso da lei. De outra forma, seria incoerente negar a quem tem por função salvaguardar a ordem pública o direito (e o dever) de prestar contas de sua função, justamente quando a cumpre a contento.

A desconsideração de depoimento de policial somente procede quando decorre de atos de parcialidade, motivados por vingança ou perseguição e desde que comprovados de forma segura e objetiva, o que efetivamente não veio a ser comprovado nestes autos. Não é suficiente a mera alegação de suspeição em virtude de simplesmente tratar-se de agentes policiais. Ressalte-se que a diligência policial promovida neste processo decorreu tão somente do patrulhamento que realizavam pela região sem que haja qualquer indício que qualquer perseguição pelos policiais houvesse em relação aos acusados, ao contrário, ambos confessaram os fatos em versões quase que idênticas as prestadas pelos policiais, o que só reforça o posicionamento desta magistrada

Confira-se:

"Prova - Testemunhal - Depoimento prestado por policiais participantes da diligência - Validade - Ausência de interesse em incriminar o réu - Recurso não provido. Os funcionários da Polícia merecem, em seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão, concreta de suspeição" (Relator: Silva Pinto, Apelação Criminal n. 153.983-3,

Santos, 7.7.94).

Imperioso ressaltar que o simples fato de o local dos fatos ser uma "escola abandonada", não é suficiente para que o crime de furto seja afastado, como quis fazer crer a Defesa, já que havia bens de valor econômico no interior do imóvel e que pertenciam ao proprietário que teve comprovada diminuição de seu patrimônio pela ação dos réus.

A qualificadora referente ao concurso de pessoas restou provada tanto pelos depoimentos prestados em Juízo pelos policiais, bem como pela confissão dos réus, que afirmaram que agiram em conjunto.

Já no que toca à escalada, de fato, como muito bem ponderado pelas partes, é o caso de afastamento da qualificadora, posto que não comprovada nos autos, diante da ausência do laudo do local dos fatos.

Com efeito, para a configuração dessa qualificadora, é indispensável o laudo pericial. Firme é a jurisprudência quanto à questão: "É imprescindível ao reconhecimento, em tema de furto, da qualificadora da escalada, a realização de exame pericial, não sendo este suprido pelo simples ato de verificação e descrição do local do delito assinado pela autoridade policial" (TJSC, JCAT 91/489).

"HABEAS CORPUS Nº 136.893 - MS (2009/0097485-2) RELATOR : MINISTRO FÉLIX FISCHER IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL ADVOGADO : SANDRA REGINA SANTOS DE VASCONCELOS - DEFENSORA PÚBLICA IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL PACIENTE : CLIMERIO LUCAS DA SILVA EMENTA PENAL. HABEAS CORPUS. artigo 155, § 4º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. QUALIFICADORA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. LAUDO PERICIAL. O exame de corpo de delito direto, por expressa determinação legal, é indispensável nas infrações que deixam vestígios, podendo apenas supletivamente ser suprido pela prova testemunhal quando os vestígios tenham desaparecido. Portanto, se era possível sua realização, e esta não ocorreu de acordo com as normas pertinentes (artigo 159 do CPP), a prova testemunhal não supre sua ausência".

Por sua vez, o artigo 171 do Código de Processo Penal, determina a necessidade de realização de perícia para a comprovação da qualificadora do rompimento de obstáculo, e da escalada, que somente pode ser substituída por outras provas quando os vestígios desaparecerem, não existirem, ou o exame técnico não for passível de implementação, o que não veio comprovado nos autos, o que faz com a que a condenação persista apenas na forma simples.

Caracterizada, portanto, a infração penal passo a dosimetria da pena:

Do réu Pedro dos Santos:

O réu é reincidente, (fls. 41, já tendo sido condenado definitivamente pela prática de roubo, perante a 13ª Vara Criminal, autos nº 0095166-50.2016.8.26.0050), o que será analisado na segunda fase de aplicação de pena. Além disso, possui outra condenação já transitada em julgado conforme certidão de fls. 40 por tráfico ilícito de entorpecentes (0025388-32.2012.8.26.0050), que será aqui considerada como Maus antecedentes, devendo a pena base ser aumentada em 1/6, nos termos do disposto no art. 59 do Código Penal, perfazendo, 2 anos, 4 meses e 11 dias-multa.

Não há que se falar em desconsideração das condenações acima apontadas apenas e tão somente pelo decurso do tempo já transcorrido, de fato, se por um lado elas não podem mais serem consideradas como agravantes em razão do disposto no art. 64, inciso I, do Código Penal, fato é que nada impede de considerá-las como Maus antecedentes, já que demonstram a personalidade criminosa do acusado, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

STJ- "condenações anteriores ao prazo depurador de 5 anos, malgrado não possam ser valoradas na segunda fase da dosimetria como reincidência, constituem motivação idônea para a exasperação da pena-base a título de Maus antecedentes" (HC 456891/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 02.10.2018).

E ainda, conforme precedente do Excelso Supremo Tribunal Federal, "não constitui ilegalidade o fato da sentença considerar os antecedentes criminais e outras circunstâncias judiciais, previstas no artigo 59, do Código Penal, aumentando, depois, a pena base, em razão da reincidência" (HC nº 1.990, Rel. Min. Carlos Veloso, DJU de 22.09.95, p. 30.591).

"Apesar de desaparecer a condição de reincidente, o agente não readquire a condição de primário, que é como um estado de virgem, que, violado, não se refaz. A reincidência é como o pecado original: desaparece, mas deixa sua mancha, servindo, por exemplo, como antecedente criminal" (BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 238).

Na segunda fase, respeitado entendimento diverso, há que se considerar que o crime foi cometido em situação de calamidade pública tendo em vista a pandemia que assola o país por conta do Corona vírus - COVID-19, reconhecida por meio do Decreto nº 64.879/2020 de 20/03/2020, que até os dias atuais vem ocasionado efeitos desastrosos em nossa poluição.

E neste ponto, para esta magistrada, é notório que o estado de calamidade pública acabou por facilitar a execução de crimes, ainda mais diante da necessidade de isolamento social a fim de retardar a propagação da doença, o que gerou a redução de pessoas e policiais nas ruas, defasando a vigilância estatal. Veja-se que na época desses fatos, mais uma variante do vírus denominada Ômicron, estava fazendo inúmeras vítimas fatais e as restrições, voltaram a ser mais rigorosas, para evitar a propagação do vírus. Também é o caso de se reconhecer a atenuante da confissão e, portanto, a pena deve ser mantida no patamar já fixado já que atenuante e agravante se compensam, segundo entendimento pretoriano que vem se solidificando em nossos Tribunais.

Presente ainda no presente caso, a agravante da reincidência e assim sendo a pena deve ser agravada em 1/6, chegando-se a 2 anos, 8 meses e 20 dias, e 12 dias-multa.

O crime, contudo foi tentado, já que os réus não conseguiram consumir a subtração pois foram surpreendidos pela polícia no momento que tentavam pular o muro com os objetos em mãos e assim acabaram sendo presos.

Nesse ponto, considerando o iter criminoso praticado pelos réus, que já haviam separado todos os bens e já estavam no muro prontos para sair do local, a pena deve ser diminuída no mínimo legal de 1/3, e será fixada em 01 ano, 09 meses e 23 dias, e 08 dias-multa.

Nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal, o réu iniciará o cumprimento de pena em regime fechado, posto que reincidente e com maus antecedentes também apontados nos autos.

Veja-se que no caso em tela o réu já foi condenado definitivamente pelos crimes de roubo e de tráfico, e descumpriu as condições impostas ao cumprimento de pena em regime aberto e novamente se viu na prática de crime contra o patrimônio, o que demonstra que não está apto a se inserir em liberdade e que neste momento, o cárcere é o que lhe convém. Por seu turno, a imposição do regime prisional independe da quantidade de pena aplicada na r. sentença circunstâncias judiciais indicadas no artigo 59, do Código Penal, observado o que dispõe o artigo 33, § 3º, do mesmo Diploma.

Nessa conformidade, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"Se o condenado, mesmo com pena inferior a 4 anos de reclusão, é reincidente, como reconhecido pela sentença de 1º grau, não faz jus ao regime semi-aberto para início da execução da pena" (RT 725/533).

"O réu reincidente, apenado com reclusão, pouco importa o grau da pena privativa de liberdade, deverá iniciar o cumprimento pelo regime fechado. Infringência ao disposto no art. 33, § 2º, 'a', 'b' e 'c', do CP. Recurso provido" (STJ, Resp. 84669/SP, 5ª Turma, Rel. Min. Félix Fischer, DJU 14.4.97).

"embora o quantum da pena aplicada permita a adoção do regime inicial mais brando, os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal (maus antecedentes), além da presença da reincidência, recomendam que seja adotado regime mais gravoso, sendo inadequada, in casu, a fixação de regime diverso do fechado" (STJ, AgRg no RESp 1.899.462/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021).

Em síntese, certo que a determinação do regime prisional não é mero consectário da quantidade da pena reclusiva imposta, devendo ser levados em consideração os fatores contemplados no art. 59 do CP. (cf., exemplificativamente, ac. un. na Ap. nº 673.255/1, de São Paulo).

Por fim, incabível possível a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, nos termos do que dispõe o art. 44, §3º, do Código Penal, bem como o sursis.

De outra banda, em razão de estar respondendo ao processo preso, tem-se entendido que seria um contrassenso libertá-lo após a sentença que o condenou. Assim, não poderá recorrer desta sentença em liberdade. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra, já que continuam intactos os motivos que levaram à sua prisão preventiva que deve ser mantida, notadamente para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

Em atenção ao determinado no art. 316, parágrafo único, do Código Processual Penal, já com a nova redação, dou por revisada a prisão cautelar do acusado que deve ser mantida pelas razões acima expostas.

Da ré Cintia:

A ré é primária e não possui antecedentes criminais atestados nos autos. Assim sendo a pena base deve ser fixada no mínimo legal de 02 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase, pelos fundamentos acima expostos, há que se reconhecer a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "j", já que o crime foi praticado em situação de calamidade pública tendo em vista a pandemia que assola o país por conta do Corona vírus - COVID-19, reconhecida por meio do Decreto nº 64.879/2020 de 20/03/2020, que até os dias atuais vem ocasionado efeitos desastrosos em nossa poluição. Também é o caso de se reconhecer a atenuante da confissão e, portanto, a pena deve ser mantida no patamar já fixado já que atenuante e agravante se compensam, segundo entendimento pretoriano que vem se solidificando em nossos Tribunais. Por outro lado, não há nos autos provas da menoridade da ré, que segundo auto de qualificação de fls. 29 tem 28 anos de idade.

O crime, contudo foi tentado, já que os réus não conseguiram consumir a subtração pois foram surpreendidos pela polícia no momento que tentavam pular o muro com os objetos em mãos e assim acabaram sendo presos.

Nesse ponto, considerando o iter criminis praticado pelos réus, que já haviam separado todos os bens e já estavam no muro prontos para sair do local, a pena deve ser diminuída no mínimo legal de 1/3, e ser fixada em 01 ano, 04 meses e 06 dias-multa.

Considerando a primariedade da acusada Cíntia, bem como que o crime foi praticado sem violência ou grave ameaça e o montante de pena aplicada, nos termos do disposto no art. 44 do Código penal, cabível, à ré Cíntia, a substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, pelo mesmo tempo da pena substituída e que deverá ser determinada e fixada no Juízo da Execução, nos moldes requeridos pelo Ministério Público, (frequência de curso se o caso, sem o prejuízo do pagamento das diárias mínimas estabelecidas.

Em caso de eventual descumprimento, o regime inicial de cumprimento de pena deve ser o aberto.

Considerando a pena aplicada, poderá a ré apelar em liberdade.

Expeça-se alvará de soltura clausulado, com urgência, em favor da acusada Cintia.

Após, o trânsito em julgado, expeça-se guia, oficiem-se aos TRE e ao IIRGD.

Elabore-se cálculo, que fica desde já homologado, salvo se houver impugnação de alguma das partes.

Com a juntada do cálculo aos autos, abra-se vista às partes para ciência e eventual manifestação.

Comunique-se a vítima, consoante disposição legal.

Custas na forma da lei, ressalvado o previsto no art. 98, §3º do Código de Processo Civil, que expressamente revogou o art. 12 da Lei 1.060/50.

P.R.I.C.

São Paulo, 08 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA